

1500894-30.2019.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295895/2019 - DEL.POL.LINDOIA, 7913030 - DEL.POL.LINDOIA, 210/19/107 -

DEL.POL.LINDOIA, 2295895 - DEL.POL.LINDOIA, 210/19/107 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia-SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500894-30.2019.8.26.0035 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-30.2019.8.26.0035

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295895/2019 - DEL.POL.LINDOIA, 7913030 - DEL.POL.LINDOIA, 210/19/107 -

DEL.POL.LINDOIA, 2295895 - DEL.POL.LINDOIA, 210/19/107 - DEL.POL.LINDOIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SARAH MAYARA REZENDE DAMIAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de FELIPE AUGUSTO LOURENÇO e SARAH MAYARA REZENDE DAMIÃO, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06)

Narra-se na denúncia, em resumo, que no dia 09/10/2019, as 22:40 da noite, na cidade de Lindóia-SP, os réus foram presos em flagrante transportando consigo para consumo de terceiros, 12 (doze) porções individuais de crack, pesando cerca de 2 gramas, 1 papelote de cocaína, pesando aproximadamente 0,7 gramas e bitucas de cigarro de maconha, pesando 1,6 gramas, destinadas a uso próprio, sem autorização ou regulamentação legal. (fls.1/2)

A denúncia foi recebida em 18/10/2019.

Promovida a citação (fl.124), sobreveio a resposta a acusação (fls. 159/166).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art 397), designou-se audiência de introdução e julgamento, na qual foi produzida prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal, bem como a defesa.

No curso do processo, houve a prisão cautelar do acusado Felipe Augusto Lourenço, entre as seguintes datas: 09/10/2019 a 24/01/2020.

Após, vieram os autos conclusos para a sentença.

É o relatório.

Não há questão preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), pelo auto de apreensão (fls. 6 e 7), pelo laudo de exame pericial (pericial- fls. 256/264), bem como os depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Felipe Lefort Costa afirmou que, estava em patrulhamento e em determinado lugar sentiu o cheiro de cannabis sativa (maconha) e observou duas pessoas; abordou Felipe e não achou nada; Sarah foi abordada pela colega Paula e foi encontrado os entorpecentes; não se recorda em questão do dinheiro encontrado; havia obtido uma denúncia de tráfico de entorpecente entre os prédios; não especificando o casal; informaram sobre a relação; não conhecia os réus, apenas o local; informaram ao policial que estavam de mudança; estavam vendendo os entorpecentes; era tarde da noite, não se recorda o horário; sem mais informações. Por fim, a acusada em interrogatório Sarah Mayara aduziu que os entorpecentes era para o uso de Felipe, apenas; localizavam-se no estacionamento fumando e receberam a abordagem; os dois trabalhavam no carrinho de lanches e estavam de mudança; não tem antecedentes criminais; o dinheiro encontrado era referente ao troco de uma compra; tinham uma relação na época dos fatos; não utilizavam ou guardavam as drogas dentro de casa; Felipe já foi internado diversas vezes pelo vício; Já o acusado Felipe Augusto Lourenço em interrogatório aduziu que, estava arrumando suas coisas para mudança; saiu para a utilização das drogas no estacionamento com a Sarah e recebeu a abordagem; trabalhavam em um carrinho de lanches na porta de sua casa; não tem antecedentes criminais; não utilizava drogas dentro de casa; é usuário de drogas há 13 anos; já foi internado diversas vezes (não soube especificar) e uma com medidas judiciais; o dinheiro encontrado era dos trabalhos realizados no dia da abordagem.

Quanto à tipificação, impõe-se a desclassificação, conforme reconhecido pelo Ministério Público.

É cediço que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) consiste em tipo misto alternativo com 18 (dezoito) núcleos do tipo e sem elementos subjetivos especiais, ao passo que o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para uso pessoal) consiste também em tipo misto alternativo com 5 (cinco) núcleos do tipo, todos eles também constantes do art. 33, mas com a distinção de um elemento subjetivo especial: a destinação do objeto material do crime (droga) ao consumo pessoal.

Diante de tais figuras típicas similares, distintas sobretudo pela destinação da droga, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece os critérios que devem ser considerados pelo órgão julgador para estabelecer se a droga tinha destinação ao consumo pessoal: (i) a natureza e a quantidade da substância apreendida (circunstâncias objetivas), (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação (circunstâncias espaciais), (iii) as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (circunstâncias subjetivas).

Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra probatória que dele decorre, é forçoso reconhecer que a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso (art. 33) depende do afastamento, para além de dúvida razoável, da destinação da droga ao uso pessoal (art. 28), mediante verificação dos critérios legais

constantes do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. Do contrário, na situação de dúvida, deve esta ser resolvida em favor do acusado, com a subsunção ao tipo penal menos gravoso, consectário dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei. Nesse sentido, vale conferir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.769.822/PA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2018).

No caso, não há prova segura a indicar a destinação ao tráfico, considerado as uníssonas e verossímeis versões dos acusados, não contrariadas pelo relato dos policiais relativo à abordagem ocasional e não precedida de investigação prévia. Uma vez operada a desclassificação, é forçoso reconhecer que, no curso da persecução penal, foi decretada a prisão provisória. As sanções penais aplicáveis ao crime praticado pelo acusado (art. 28 da Lei n. 11.343/06), por sua vez, são simplesmente penas restritivas de direito, tendo em vista ser inaplicável ao referido crime qualquer modalidade de pena privativa de liberdade (“despenalização”, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da QO no RE 430.105).

Em tal cenário, à luz do que ordena o art. 42 do Código Penal (cômputo do tempo de prisão provisória como cumprimento de pena: detração), o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconheceu o prévio exaurimento da pretensão punitiva e a falta de interesse na aplicação da pena em razão do cumprimento de prisão provisória de natureza mais gravosa que a própria pena aplicável ao crime, de modo a justificar a declaração da extinção de punibilidade.

A saber, tal corte de superposição reconhece a incidência da assim denominada “detração penal analógica virtual” em tais situações em que a prisão cautelar cumprida no curso do processo mostra-se por si só mais gravosa do que a pena abstratamente aplicada ao crime ao final reconhecido como praticado. Nesse sentido, confirmam-se: STJ, REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, e STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/2018.

Por tais razões, deve ser aplicada a detração penal analógica virtual e reconhecida a extinção de punibilidade pelo prévio exaurimento da pretensão punitiva pela aplicação de prisão preventiva desproporcional à gravidade da infração penal verificada.

Ante o exposto, tendo em vista a desclassificação da infração para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a prisão preventiva do acusado no curso do processo, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados FELIPE AUGUSTO LOURENÇO e SARAH MAYARA REZENDE DAMIÃO, com supedâneo no artigo 42 do CP.

Promova-se a destruição das amostras de droga eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Sem custas (CPP, art. 804).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Águas de Lindoia, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA